

# 第73問

甲は、A国立大学の音楽学部に所属する教授であるが、楽器業者である乙に「A大学の学生に乙のヴァイオリンを買うようあっせんしてくれませんか。お礼はもちろんさせていただきますので。」などと言われ、これを承諾した。甲は、乙との約束に従い、A大学の授業中に、生徒に対して、乙のヴァイオリンが優れており、購入するべきである旨を告げ、その見返りとして、乙から100万円を受け取った。なお、A国立大学の学則上、音楽学部教授が生徒に対して特定の事業者から楽器を購入するよう勧めることを禁止する規定はなく、また、乙のヴァイオリンの販売価格は市場価格と大差ないものであった。

丙は、楽器業者であるが、甲と乙のやりとりを知り、A大学に対して苛立ちを覚えたため、ある日の深夜、A大学の校門前に大量の木材を釘などでつなぎ合わせて壁を作り、学生や教授が校門から出入りできないようにした。

丙の上記行為には事件性があると判断した警察官Bは、捜査を開始したところ、丁が深夜にA大学前をうろついており、施錠されたA大学の校門をまさに乗り越えようとしていた。警察官Bは、丁に対して「そこで何をしているんだ。」と質問した。丁は、A大学の職員で、職務室に忘れてきた書類を取りにA大学構内に立ち入ろうとしただけであり、実際に立ち入る権限もあったため、警察官に質問されるいわれはないと思ったが、突然の事態に驚き、無言でいたところ、Bは丁に対して「お前が犯人だな。」などと言いながら、同人の身体を拘束しようとした。丁は逮捕される筋合いはないと考え、Bに対して、手拳で殴るなどの暴行を加えた。

甲、乙、丙及び丁の罪責について論じなさい。なお、国立大学法人法により、国立大学法人の役員及び職員は、刑法の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされている。

## 第1 甲の罪責

- 1 甲は乙からの依頼に基づき、ヴァイオリンの購入をA大学の学生に勧め、その見返りとして乙から100万円を受け取っているから、受託収賄罪（197 I 後段）の成否が問題となる。
- 2 問題となるのは、職務関連性の要件である（**論点**「職務に関し」の意義、**論点** 賄賂の罪の保護法益）。職務関連性は職務密接関連性まで含むと解されるところ、本問同様の事案において、東京地判昭60.4.8は、職務密接関連行為性を肯定した。  
甲には、受託収賄罪が成立する。

総合 289 頁 論証 155 頁  
総合 289 頁 論証 154 頁

## 第2 乙の罪責

甲の上記行為に対応した金銭の供与について、贈賄罪（198）が成立する。

## 第3 丙の罪責

丙は、A大学の校門前に壁を作り、同大学の学生や教授が校門から出入りできないようにしており、威力業務妨害罪（234）の成立が考えられる。

この点について、A大学は国立大学であるから、いわゆる公務と業務の関係性が問題となる（**論点** 公務執行妨害罪・業務妨害罪における公務と業務 ■ 司H21,JBH19-2）。

総合 190 頁 論証 79 頁

判例は、強制力を行使する権力的公務と非権力的公務に二分し、後者については「業務」に含まれるという立場を採ると解されている（最大判昭41.11.30、最決昭62.3.12、最決平12.2.17【百選Ⅱ23】、最決平14.9.30【百選Ⅱ24】等）から、判例に従えばA大学に対する威力業務妨害罪が成立する。

## 第4 丁の罪責

- 1 丁は警察官Bに対して暴行を加えているから、公務執行妨害罪（95 I）の成否が問題となる。
- 2 もっとも、丁は違法行為を行っていたわけではないから、純事後的かつ客観的に見れば、Bが丁の身体を拘束しようとしたことは違法である。

そこで、いわゆる公務の適法性が問題となる（**論点** 公務の適法性）。

総合 282 頁 論証 147 頁

この点について、一般に、①一般的職務権限に属していること、②具体的職務権限に属していること、③重要な条件及び方式を履践していることが公務の適法性の要件となると解されている。

もっとも、これをどのような観点・基準で判断するのが問題となる。

判例（最決昭41.4.14【百選Ⅱ113】）は一般的に、行為時を基準として、裁判所の立場から客観的に適法性の有無を検討する見解（やわらかな客観説）に立っていると評価されている（「行為当時の状況に基づいて客観的、合理的に」判断すべきとした原審を「相当である」として是認した。）。

この立場からすると、施錠されたA大学の校門をまさに乗り越えよう

としていた丁が、A大学への立入り権限があるとは思えないから、行為時の事情からすれば、建造物侵入罪（130前段）が成立すると考えられる。このように考えれば、職務の適法性を肯定することができるだろう。

もっとも、丁は、逮捕されるいわれはないと考えており、職務の適法性について錯誤がある（**論点** 職務執行の適法性の錯誤）。

かかる錯誤の取扱いについて、通説は、公務員の職務の適法性を基礎づける事実の認識がない場合には事実の錯誤として故意を阻却するが、公務の適法性を基礎付ける事実を認識していた場合には、法律の錯誤となり（原則として）故意は阻却されないとする、いわゆる二分説に立つと評価されている。

本問では、公務員の職務の適法性を基礎づける事実の認識は認められるだろうから、この立場に立てば故意阻却はなく、公務執行妨害罪は成立することになる。

総合 282 頁 論証 148 頁

### 第1 甲の罪責

#### 1 受託収賄罪（197 I 後段）の成否

↓

#### 2 「公務員」「請託」「賄賂」「收受」

↓

「職務に関し」といえるか

↓

職務として行い得る一般的抽象的な範囲にあればよく、また職務と密接に関連する行為も含む

↓

あてはめ

↓

「職務に関し」といえる

↓

#### 3 受託収賄罪成立

### 第2 乙の罪責

贈賄罪成立

### 第3 丙の罪責

#### 1 公務執行妨害罪（95）不成立

↓

#### 2 威力業務妨害罪（234）の成否

↓

公務は「業務」に含まれるか

↓

強制力を行使する権力的な公務は含まれないが、そのような強制力を行使しない非権力的公務は含まれる

↓

あてはめ

↓

#### 3 威力業務妨害罪成立

### 第4 丁の罪責

#### 1 公務執行妨害罪の成否

↓

#### 2 「職務」の適法性

↓

記述されざる構成要件要素

↓

①一般的職務権限及び②具体的職務権限に属しており、③重要な条件及び方式を履践している場合に認められる

↓

適法性は行為時の状況を基礎にして、法令の客観的な解釈によって判断されるべき

↓

あてはめ

↓

「職務」の適法性肯定

↓

丁の行為は公務執行妨害罪の客観的構成要件に当たる

↓

3 職務の適法性の錯誤

↓

二分説

↓

あてはめ

↓

丁には公務執行妨害罪が成立する



## 第1 甲の罪責

1 甲は乙からの依頼に基づき、ヴァイオリンの購入をA大学の学生に勧め、その見返りとして乙から100万円を受け取っているから、受託収賄罪（197条1項後段）の成立が考えられる。

2(1) 甲は、A国立大学の音楽学部に所属する教授であり、「公務員」に当たる。また、乙からヴァイオリン購入のあっせんについて「請託」も受けている。では、本件において、「賄賂」に当たる100万円は、「職務に関し」て「収受」（同項前段）したものに当たるか。

本罪の趣旨は職務の公正と社会一般の信頼を保護する点にある。そうだとすれば、当該公務員が法律上有する権限でなくても、本条の対象にする必要がある。

したがって、ここにいう「職務」とは、職務として行い得る一般的抽象的な範囲にあればよく、また職務と密接に関連する行為も含むといふべきである。

(2) 甲は、生徒に対して、特定の楽器商の保有するヴァイオリン購入の勧告をする行為は、甲の本来の職務である、生徒の演奏技術の向上に努めることと深く関連しているといえるし、また、甲は授業中にかかる勧告を行っているから、その地位を利用しているものといえる。

したがって、職務と密接に関連する行為である。

(3) よって、「職務に関し」の要件も満たされる。

3 以上から、甲には受託収賄罪が成立する。

## 第2 乙の罪責

1

乙には、甲の上記行為に対応した「賄賂を供与」した行為について、贈賄罪（198条）が成立する。

## 第3 丙の罪責

1 丙は、木材をつなぎ合わせて壁を作ったのみであり、「公務員」に対して「暴行又は脅迫を加えた」わけではないので、公務執行妨害罪（95条1項）は成立しない。

2(1) もっとも、上記行為は人の意思を制圧するに足りる勢力を用いるものとして「威力」に当たるところ、これによって学生や教授が校門から出られないようにしているから、威力業務妨害罪（234条）の成立が考えられる。

もっとも、A大学は国立大学であるから、A大学の行う職務は公務に当たる。では、このような公務も「業務」に含まれるのか。

この点について、強制力を行使する権力的公務については威力・偽計は実力で排除できるが、そのような強制力を行使しない非権力的公務についてはそのような実力はない。しかも、非権力的公務は私人の業務と区別する必要がなく、「業務」に当たるとしても無理はない。

したがって、非権力的公務のみが「業務」に含まれると解する。

(2) A大学は教育を目的とする機関であり、その業務に強制力を行使するような要素はないから、「業務」に当たる。

3 したがって、丙には、「威力を用いて人の業務を妨害した」として、威力業務妨害罪が成立する。

## 第4 丁の罪責

2

1 丁は「公務員」たる警察官Bが「職務を執行するに当たり」、これに  
2 対して「暴行」を加えているから、公務執行妨害罪（95条1項）の成  
3 立が考えられる。

4 2(1) もっとも、丁には、A大学構内に立ち入る権限があるから、建造物  
5 侵入罪（130条前段）は成立せず、「罪を行い、又は現に罪を行い  
6 終わつた者」（刑事訴訟法212条1項）とはいえない。

7 したがって、事後的かつ純客観的にみれば、これを現行犯逮捕しよ  
8 うとしたBの行為は違法である。では、違法な「職務」も公務執行妨  
9 害罪の保護の対象となるか。

10 (2) 本条の趣旨は公務の適正な執行を保護する点にある。そうだとすれ  
11 ば、職務の適法性は記述されざる構成要件要素というべきであり、違  
12 法な「職務」は同罪の保護の対象とはならない。そして、公務の適法  
13 性は、①一般的職務権限及び②具体的職務権限に属しており、③重要  
14 な条件及び方式を履践している場合に認められる。

15 Bの行為は、①③には問題がないものの、上記のように事後的かつ  
16 純客観的にみれば、現行犯逮捕の要件を満たしておらず、②を充足し  
17 ていないから、違法であって、公務執行妨害罪で保護される「職務」  
18 には当たらないとも考えられる。

19 しかし、適正な手続を踏んで、行為時に適法であった行為は、公務  
20 の円滑な執行の観点からひとまず保護する必要性があり、適法性は行  
21 為時の状況を基礎に判断すべきである。また、職務の適法性は、規範  
22 的構成要件要素であるから、法令の客観的な解釈によって判断される

3

べきである。

(3) 以上に従うと、深夜にA大学前をうろついており、施錠されている  
校門を乗り越えようとしている丁には、客観的に見て同大学への立入  
り権限がないと考えられる。そうだとすれば、丁について建造物侵入  
罪（130条前段）が成立すると考えて、現行犯逮捕をしたBの行為  
は②を満たし、適法であるというべきである。

したがって、上記職務は適法であるから、公務執行妨害罪で保護さ  
れる「職務」に当たる。

(4) 以上から、丁の行為は公務執行妨害罪の客観的構成要件に当たる。

3(1) もっとも、丁は、A大学構内に立ち入る権限があるから、逮捕され  
るいわれはないと考えており、職務の適法性について錯誤がある。

そこで、丁には公務執行妨害罪の故意（38条1項）が認められな  
いのではないか。

(2) 職務の適法性を基礎付ける事実を誤信した場合、行為者には規範の  
問題が与えられておらず、事実の錯誤として故意が阻却される。他  
方、職務の適法性を基礎付ける事実を認識していた場合には、法律の  
錯誤となり故意は阻却されない。

(3) 本件では、丁は自らが深夜施錠されているA大学の校門を乗り越え  
ようとしていることを認識しているはずであるから、職務の適法性を  
基礎付ける事実を認識していたといえる。

したがって、故意は阻却されない。

以上から、丁には公務執行妨害罪が成立する。

以 上

4